

刑法
No317

共通問題 R2-2

(配点：3)

月	日
月	日

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙からの委託に基づき、同人所有の衣類が入った、施錠されていたスーツケース1個を預かり保管していたところ、衣類を古着屋に売却して自己の遊興費を得ようと考え、勝手に開錠し、中から衣類を取り出した。この場合、遅くとも衣類を取り出した時点で不法領得の意思の発現と認められる外部的行為があったといえるから、甲には、横領罪が成立する。
2. 甲は、乙と共に一定の目的で積み立てていた現金を1個の金庫の中に入れて共同保管していたところ、乙に無断でその現金全てを抜き取り、自己の遊興費に費消した。この場合、甲には、横領罪が成立する。
3. 株式会社の取締役経理部長甲は、同会社の株式の買い占めに対抗するための工作資金として自ら業務上保管していた会社の現金を第三者に交付した。この場合、甲が、会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担を伴うもので、甲が自己の弱みを隠す意図をも有していたなど、専ら会社のためにしたとは認められないときは、甲には、業務上横領罪が成立する。
4. 甲は、乙から某日までに製茶を買い付けてほしい旨の依頼を受け、その買付資金として現金を預かっていたところ、その現金を確実に補填するあてがなかったにもかかわらず、後日補填するつもりで自己の遊興費に費消した。この場合、甲がたまたま補填することができ、約定どおりに製茶の買い付けを行ったとしても、甲には、横領罪が成立する。
5. 甲は、自己が所有し、その旨登記されている土地を乙に売却し、その代金を受領したにもかかわらず、乙への移転登記が完了する前に、同土地に自己を債務者とし丙を抵当権者とする抵当権を設定し、その登記が完了した。この場合、同抵当権が実行されることなく、後日、その登記が抹消されたとしても、甲には、横領罪が成立する。

No317

共通R2-2

横領罪

正解

1、2 (順不同)

正答率

37%

1 誤っている

本記述は、甲には、横領罪が成立するとしている点で、誤っている。

最決昭 32.4.25。本記述と類似の事案において、判例は、窃盗罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、委託された包装物(封緘物)の占有者が委託者が受託者かという点について、包装物全体には受託者が占有を有するが、内容物は委託者が占有を有しているということを挙げている。本記述では、施錠されたスーツケース全体は受託者甲が占有を有するが、中の衣類は委託者乙が占有を有するので、同衣類は「自己の占有する他人の物」(252条1項)に当たらない。したがって、甲には窃盗罪が成立し、横領罪は成立しない。

2 誤っている

本記述は、甲には、横領罪が成立するとしている点で、誤っている。

最判昭 25.6.6。本記述と同様の事例において、判例は、窃盗罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、数人が共同して財物を占有する場合、共同占有者の1人が無断で当該財物を自己の単独占有に移転することは、他の共同占有者の占有を侵害するものであるということを挙げている。したがって、甲には、窃盗罪が成立する。

3 正しい

最決平 13.11.5 (百選Ⅱ67事件)により、本記述は正しい。

行為者が委託された物を専ら本人のために処分する意思である場合、不法領得の意思が否定され、横領罪は成立しない(大判大 15.4.20)。そして、本記述と同様の事案において、判例(最決平 13.11.5)は、商法その他の法令に違反する行為をした場合であっても、「行為者の主観において、それを専ら会社のためにするとの意識の下に行うことは、あり得ないことではない」としている。しかし、判例は、被告人が会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、当該現金の交付が会社にとって重大な経済的負担を伴うもので、甲が自己の弱みを隠す意図を有していたなどの事情に着目し、専ら会社のためにしたとは認められないとして、業務上横領罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、自己の利益を図る目的と本人のためにする意思とが併存する場合には、主たる目的がどちらかによって決すべきであるということを挙げている。したがって、甲には、業務上横領罪が成立する。

4 正しい

最判昭 24.3.8 (百選Ⅱ66事件)により、本記述は正しい。

本記述と類似の事案において、判例は、業務上横領罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「横領罪の成立に必要な不法領得の意志とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意志をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではなく、又占有者において不法に処分したものを後日に補填する意志が行為当時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものでもない」ということを挙げている。したがって、甲には、横領罪が成立する。

5 正しい ★

最決平 21.3.26 により、本記述は正しい。

既に譲渡済みであるが、所有権移転登記が未了であった建物を保管していた被告人が、同建物に虚偽の抵当権設定登記を具備した事案において、判例は、業務上横領罪が成立するとしている。その理由として、判例は、「仮登記を了した場合、それに基づいて本登記を経由することによって仮登記の後に登記された権利の変動に対し、当該仮登記に係る権利を優先して主張することができるようになり、これを前提として、不動産取引の実務において、仮登記があった場合にはその権利が確保されているものとして扱われるのが通常である。以上の点にかんがみると、不実とはいえ、本件仮登記を了したことは、不法領得の意思を実現する行為として十分である」ということを挙げている。不実の仮登記の場合でも不法領得の意思の実現と認められるとする判例の立場からすれば、本記述の甲は、真正な抵当権設定登記を完了させている以上、不法領得の意思が実現しているとみてよい。また、不法領得の意思が実現した時点で横領罪が既遂に達するため、本記述のように同抵当権が実行されることなく登記が抹消されたとしても、横領罪の成否に影響はない。したがって、甲には、横領罪が成立する。

以上により、誤っている記述は1と2であり、したがって、正解は肢1と肢2（順不同）となる。